

1500647-50.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... não há dúvida de que o acusado estava praticando o tráfico.

É necessária a análise conjunta dos requisitos previstos no art. 28, §2º da Lei 11.343/06 para a distinção entre o usuário e o traficante.

No caso em tela, o réu foi flagrado em ponto de tráfico, na posse de vinte e uma porções de cocaína e dinheiro em notas de pequenos valores (R\$ 160,00), e visto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500647-50.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500647-50.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2156362/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 18406570 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2621/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2156362 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2621/21/050 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD RAFAEL FELIX

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

RICHARD RAFAEL FELIX foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 09 de junho de 2.021, por volta das 19h30, na rua Alfredo Gonçalves D'Abril quadra 05, Jardim Ivone, nesta cidade, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 20,20 gramas de cocaína, subdivididos em 72 porções, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 88), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 93/94.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 20 de julho de 2.021 (fls. 106/108).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 168 -

audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 173/176).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 181/222, alegando que: 1)- as provas são frágeis; 2)- os policiais não qualificaram civis presentes no local, bem como não efetuaram campanhas ou investigações, e nem afirmaram que o réu entregava droga ao motociclista; 3)- não foram comprovados os atos de mercancia; 4)- ninguém, encontrado com pequena quantidade de droga em seu poder e sem nenhuma prova contundente de tráfico, iria indicar local onde estariam outros 51 pinos de cocaína, encontrados somente com ajuda do cão farejador; 5)- a confissão informal é nula; 6)- os depoimentos dos policiais não são suficientes para a condenação; 7)- deve a conduta ser desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, observado que, se o réu indicou aos policiais onde estavam os pinos no terreno, não seria necessário cão farejador, e que o fato de as drogas serem idênticas nada prova, pois, em mais de 90% dos casos de apreensão de cocaína, ela é encontrada em pinos plásticos transparentes; 8)- o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas. Pediu a absolvição e, alternativamente, a desclassificação da conduta, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a fixação do regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 14 e pelo laudo pericial de fls. 68/71 (vinte e uma porções de cocaína com peso de 5,60 gramas; e cinquenta e uma porções de cocaína com peso de 14,60 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Em juízo, a testemunha Hugo Kiitiro Kato Cassiano de Lara, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento e, ao adentrar na via pública em questão, viu o réu entregando algo a um motociclista. Ao ver a viatura, o condutor da moto fugiu. O réu foi abordado. Com ele, foram localizados alguns pinos de cocaína e dinheiro. Indagado, o acusado confessou que praticava o tráfico no local e que havia mais porções de droga em um terreno baldio ao lado. Com apoio de cão farejador, foram encontradas, embaixo de uma sacola, mais pinos de cocaína, idênticos aos localizados na posse do réu. Não lembra a cor dos pinos; porém, recorda-se que eram iguais. O acusado estava em frente a uma casa e, ao lado desta, ficava o terreno baldio onde achadas as demais porções de cocaína. Não conseguiu ver o que o réu entregou ao motorista da moto. Quando os policiais chegaram com a viatura, alguém gritou para avisar da presença da polícia. O dinheiro apreendido com o réu estava em notas de valores pequenos. Não se lembra, no entanto, quais eram esses valores. O acusado admitiu que o dinheiro era proveniente da venda da droga. Não o conhecia. O local do fato é ponto conhecido pelo tráfico de entorpecentes. De vez em quando, faz patrulha naquela região, mas não de forma tão corriqueira. Faz cobertura em toda cidade de Bauru. Nas vezes em que patrulhou o local, não viu o réu por ali. A testemunha Leandro Marcelino Pereira, também policial militar, disse que fazia patrulhamento preventivo no bairro Jardim Ivone. Quando se aproximou de uma esquina conhecida pelo tráfico, viu o réu entregando algo a um motoqueiro. O condutor do veículo saiu ao ver a viatura, enquanto o réu foi abordado. Com ele, foram localizados, nas suas vestes, cerca de vinte pinos de cocaína e mais de cem reais em dinheiro. Indagado, o réu confessou a mercancia e informou que havia mais pinos de droga no terreno baldio ao lado da casa em cuja frente estava. Com auxílio do cão farejador, o terreno foi vasculhado e foram encontrados outros cerca de cinquenta pinos, iguais aos encontrados com o réu, próximos a sacos de cimento. Os pinos eram todos iguais, mas não se recorda a cor deles. O acusado explicou que buscava droga no terreno para entregar aos usuários. Ele estava a cerca de cinco metros do terreno. Quando o viu, ele aparentava estar entregando algo para o motociclista. Não notou o que estava sendo entregue. O dinheiro apreendido estava em notas de valores pequenos, mas não se recorda quais eram. O local em que foram localizadas as porções de cocaína no terreno foi exatamente aquele indicado pelo

réu. Não o conhecia. Ele disse que o entorpecente estava perto dos sacos de cimento. O acusado também disse que estava vendendo drogas há pouco tempo, pois tinha perdido o emprego e estava tentando conseguir dinheiro. Interrogado em juízo, o réu afirmou que havia deixado a moto em um "disque" bebidas. Foi ao local para comprar drogas. Comunicou o traficante que queria entorpecente. A viatura virou. Foi abordado pelos policiais. Eles o conduziram a um terreno com um cão farejador e lhe imputaram a propriedade das drogas lá encontradas. Fizeram-no confessar, no telefone de Hugo, que o entorpecente lhe pertencia. Possuía R\$ 160,00 no bolso, provenientes do trabalho de entregas que fazia.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

A prática do delito foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, segundo os quais o réu foi flagrado entregando algo a um motociclista que se evadiu ao vê-los, a par de portar vinte e um pinos de cocaína e dinheiro em notas de pequenos valores. Ainda de acordo com as testemunhas de acusação, em local indicado pelo acusado num terreno baldio e com ajuda de cão farejador, foram localizados outros cinquenta e um pinos de cocaína.

As afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Não bastasse, a experiência tem demonstrado que, quando arroladas como testemunhas de tráfico pessoas de fora dos quadros da polícia, elas invariavelmente não dizem a verdade em juízo, pois não querem se expor a delatar publicamente um traficante, possivelmente com medo de eventuais represálias, ou mesmo por terem algum vínculo de intimidade ou amizade com a pessoa processada.

Sob tal ótica, descabe o argumento da defesa, no sentido de que os policiais deveriam ter qualificado testemunhas civis.

Insista-se: quem, afinal, estaria disposto a delatar publicamente um traficante ? Por outro lado, não há dúvida de que o acusado estava praticando o tráfico.

É necessária a análise conjunta dos requisitos previstos no art. 28, §2º da Lei 11.343/06 para a distinção entre o usuário e o traficante.

No caso em tela, o réu foi flagrado em ponto de tráfico, na posse de vinte e uma porções de cocaína e dinheiro em notas de pequenos valores (R\$ 160,00), e visto entregando algo a um motociclista que se evadiu ao ver os policiais.

Trata-se de atitude típica de tráfico, consoante se extrai do seguinte julgado: "Portanto, para a correta tipificação da conduta, é fundamental que o Julgador verifique as particularidades do delito, atentando-se à natureza e quantidade da droga, bem como ao local em que se desenvolveu a ação delitativa, às circunstâncias nas quais estava o agente. In casu, foram arrecadadas 3,60g da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "crack", sendo certo que a aludida droga estava separada em vinte e uma porções, propícias ao comércio." (TJ-MG, Apelação Criminal 10481100114174001, Des. Rubens Gabriel Soares - Relator).

Acrescente-se que o réu, embora tenha dito que o dinheiro era fruto de seu trabalho de entregador, não fez qualquer prova do alegado.

E comprovação a respeito, diga-se, não seria nada difícil.

A tudo some-se, ainda, que o acusado não explicou o motivo de estar em contato com um motociclista que se evadiu ao notar a chegada da viatura policial, e muito menos esclareceu qual objeto lhe entregou.

Se não estivesse cometendo tráfico, esclarecimentos nesse sentido ele teria prestado.

Argumentou a defesa, mais, que, se os pinos de cocaína encontrados no terreno estavam em local indicado pelo réu, não haveria motivo para vistoria com cão farejador da polícia.

Ocorre que a utilização do animal, num terreno baldio, visando localização de entorpecentes, pode ter diversas motivações, inclusive em situações em que alguém diga aos policiais onde se encontra o material ilícito.

Um deles é fácil de intuir: os policiais poderiam não acreditar na afirmação do acusado, a dar conta de que aquele indicado era o único local de guarda de entorpecente.

Se nutria dúvida quanto ao ponto em questão, cumpria à defesa indagar aos policiais o motivo das buscas por meio do cachorro.

Tampouco procede a tese de que pinos de cocaína quase sempre são transparentes.

Ao contrário, na prática forense de uma Vara Criminal, não são raros depoimentos de policiais afirmando que a apreensão recaiu sobre eppendorfs de determinada cor.

Por fim, a alegação de ser improvável que alguém, encontrado na posse de pequena quantidade de droga, indique local diverso onde existem outras porções do mesmo material, não resiste a uma análise empírica.

Isto porque não é igualmente raro que acusados de tráfico dispostos a confessar o crime compareçam perante o magistrado e, no interrogatório, admitam exatamente aquilo que a defesa pretende refutar, ou seja: que indicaram aos policiais onde outra parte do entorpecente estava escondido.

Ainda no ponto em questão, deve-se dizer ser comum que pessoa flagrada em situação comprometedoras pela polícia ou por quem quer que seja sinta-se de alguma forma compelida a desde logo admitir a culpa, no "calor" dos acontecimentos, como que buscando um momento de redenção.

No caso, não foi diferente: o acusado sabia ter sido flagrado entregando droga a um motociclista e estava na posse de dinheiro e de vinte e uma porções de cocaína em local conhecido como ponto de tráfico.

Ele próprio sabia que apenas essa situação já era suficiente para caracterização do tráfico. Tanto assim que, posteriormente, de forma mais calculista e sabendo não ter nada a perder, veio em juízo e disse que não portava droga e que não fez entrega a um motociclista.

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Em suma, a condenação na forma proposta na denúncia é medida de justiça.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu não tem antecedentes criminais.

Diante disso, fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

A atenuante da menoridade relativa não tem repercussão na redefinição do montante da reprimenda, em face do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Conclui-se que deve ser aplicado o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11343/2006.

Destaque-se que as quantidades de droga e de dinheiro apreendidas não eram das mais elevadas, não sendo possível inferir, a partir daí, que o réu se dedicava a atividade criminosa.

Tampouco existe elemento de convicção a apontar ser ele traficante contumaz ou integrante de organização criminosa.

Afigura-se justo deferir a diminuição no grau máximo de dois terços, tendo em vista que as quantidades de drogas e de dinheiro apreendidas foram pequenas.

Destarte, a pena resulta em um ano e oito meses de reclusão, mais cento e sessenta

e seis dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena para o tráfico, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

Ainda, no Habeas Corpus n. 137458/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim dissertou:

"Destaco que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto, atentando-se aos preceitos estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal. Assim, não sendo a paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a hediondez do crime não constitui motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. Fixo, ainda, o regime aberto de início do cumprimento da pena".

Assim, ausente a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado para o tráfico, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de se definir o regime no qual o acusado começará a cumprir a sanção.

Considerando as circunstâncias expostas (primariedade, ausência de antecedentes, pequenas quantidades de droga e de dinheiro), fixa-se o regime inicial aberto.

Levando em conta as mesmas circunstâncias, entende-se cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

E ainda:

"Entorpecente Absolvição ou Desclassificação - Impossibilidade - Provas seguras que demonstram a prática do delito de tráfico. Penas fixadas no mínimo e aplicado redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no percentual de 1/5 - Redução em 2/3 Possibilidade. Penas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cabimento. Regime prisional inicial fechado Fixação conforme preceitua o § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 Apelação do réu provida parcialmente." (TJSP, Apelação n. 0006628-72.2010.8.26.0319, rel. Pedro Menin, j. 10/04/2012).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo das penas aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o acusado Richard Rafael Felix como incurso nas penas do artigo 33, caput e §4º, da Lei 11.343/2006, a cumprir um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, calculado o valor do dia multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução. Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado. Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006. P.R.I. Bauru, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA